

1500366-66.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... e receberam informações de tráfico com características físicas. O réu foi abordado, não resistiu e localizou as porções de maconha no seu bolso. Informou a testemunha Sandro, ainda, que o réu estava sozinho. O réu, ao ser interrogado, narrou que havia acabado de adquirir as dez porções de maconha, porém, não eram destinadas ao tráfico, mas sim ao seu próprio consumo. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500366-66.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CÉSAR ROSA DA SILVA

Data da Audiência:

10/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Leonardo César Rosa da Silva. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Sandro Luiz Costa Silva e Cláudio Felipe Fernandes arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito, 10 (dez) porções de "maconha", com peso líquido de 12,92g (doze gramas e noventa e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os autos de exibição e apreensão, constatação, laudo definitivo da droga estão encartados a fls. 09/10, 12/15 e 73/75, respectivamente. A denúncia foi oferecida, o réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Na audiência de instrução e julgamento, o acusado foi interrogado e foram ouvidas testemunhas, sendo encerrada a instrução. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares efetuavam

patrulhamento de rotina no bairro Taboãozinho quando foram interceptados por um idoso, o qual indicou – com as características físicas e a forma como estava vestido – que o acusado praticava tráfico de drogas no local acima mencionado. Na diligência de verificação, de imediato puderam identificar o denunciado. Durante busca pessoal, os militares encontraram no bolso de sua jaqueta as 10 (dez) porções de maconha, todas devidamente embaladas e prontas para a imediata alienação. Encontraram também em sua posse diversas outras embalagens plásticas que seriam utilizadas no embalo de novas porções. Ante a inequívoca situação de flagrância, o acusado foi preso e conduzido a solo policial para as demais providências. Como se vê, a dinâmica dos fatos – convergência de todos os detalhes da diligência – demonstra que o acusado possuía todas as porções para fins de tráfico. O crime foi cometido em plena pandemia da “Covid-19”. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática da infração penal, alegando que droga lhe pertencia, mas se destinava ao próprio consumo. Disse que está preso por outro processo de tráfico, mas que as drogas localizadas não lhe pertenciam e apenas estava passando pelo local. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, verifica-se que a versão apresentada por ele restou ilhada nos autos, cercada pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual merece desprezo. Como dito antes, as provas carreadas aos autos são suficientes para incriminar o réu. A testemunha Sandro Luiz Costa Silva relatou que estava em patrulhamento pela Avenida Francisco Weiss Júnior, quando um senhor idoso pediu a ajuda da viatura e informou que na Rua Agide Ravacci, altura do numeral 85 estaria uma pessoa negra alta e magra com jaqueta preta fazendo tráfico de drogas. Disse que foram verificar e se depararam com o réu. Desse modo, o réu foi abordado e, depois de revistado, com ele localizaram uma sacola plástica contendo 10 porções de maconha já embaladas e várias embalagens de jujuba que seriam utilizadas para novo embalo. Indagado o réu admitiu que a droga lhe pertencia, porém seria para uso pessoal. No mesmo sentido é o testemunho de Cláudio Felipe Fernandes. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de policiais, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente compromissados. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos Pretórios: “O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e aplicação da lei penal” (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). “Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.” (STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Assim, é inolvidável que as circunstâncias que rodearam os fatos nos levam à segura conclusão de que se desenvolveram exatamente da forma descrita na denúncia. Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia é justamente a quantidade e forma de acondicionamento dos psicotrópicos apreendidos, o que não deixa dúvida de que o réu

se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. No tocante à dosimetria, a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu tem personalidade voltada à criminalidade, sendo certo que responde a outro processo por crime da mesma natureza pelo apurado nestes autos, com sentença condenatória em grau de recurso (autos n. 1501051-73.2021.8.26.0571). Ante a ausência de outros fatores que poderiam interferir na dosimetria, a pena se torna definitiva. Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, considerando a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, o regime para o início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. Mesmo que eventualmente a quantidade da pena imposta permitisse que fosse estabelecido regime inicial mais benéfico e a substituição da reprimenda, tais efeitos sempre dependerão, em última análise, do exame da culpabilidade do agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Dessa forma, diante da análise do caso concreto, consoante os termos dos arts. 59 e 33 do CP, levando-se em consideração a conduta e as gravíssimas consequências causadas à sociedade pelo crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a adoção do regime mais gravoso. Assim, a modalidade menos severa para o cumprimento da pena se mostra insuficiente e inadequada à repressão do delito. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 12 de março de 2021, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo drogas que supostamente seriam destinadas ao tráfico. Em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 10 de janeiro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado. Os policiais declararam que estavam em patrulhamento e receberam informações de tráfico com características físicas. O réu foi abordado, não resistiu e localizou as porções de maconha no seu bolso. Informou a testemunha Sandro, ainda, que o réu estava sozinho. O réu, ao ser interrogado, narrou que havia acabado de adquirir as dez porções de maconha, porém, não eram destinadas ao tráfico, mas sim ao seu próprio consumo. A versão apresentada pelas testemunhas acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Vale ressaltar que o Acusado tinha

apenas uma espécie de droga em pouca quantidade, não foi visualizado fazendo contato com outras pessoas e tampouco trazia dinheiro consigo, tudo afastando a versão de que estava vendendo os entorpecentes. Por outro lado, trazia consigo apenas 12g de maconha divididas em dez porções, o que também revela diminuta quantidade de drogas, mais uma evidência de que se tratava de porte de drogas para uso, não de tráfico. Ademais, é necessário salientar que o Acusado é primário (fls. 30) e não possui antecedentes infracionais (fls. 31). Outrossim, declarou-se usuário de maconha desde a sua prisão, conforme se verifica às fls. 16. Em outras palavras, a versão do Acusado, ou seja, de que estava ali e havia acabado de adquirir drogas para o próprio consumo não foi infirmada pela prova acusatória. Assim, requer a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da lei de Drogas e consequentemente seja declarada sua inconstitucionalidade, por violação ao princípio da vedação de punição à autolesão. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação

de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, não incidem agravantes, haja vista a primariedade do acusado. A agravante de calamidade pública descrita na denúncia deve ser afastada, uma vez que é indispensável a prova do nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico. Ainda, incide a atenuante da idade do réu, que tinha apenas 19 anos na data dos fatos (fls. 17). Na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Vejamos: Veja-se que não ficou comprovado nos autos que se dedique a práticas criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo então, todos os requisitos do redutor. Aqui, deve ser observada a regra de tratamento que emana da presunção do estado de inocência, não podendo se admitir que processos ainda em tramitação sejam utilizados para presumir-se a dedicação do Réu em atividades ilícitas. Com efeito, o fato de o Acusado responder a outro processo não o impede de receber o redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, com base no princípio da presunção do estado de inocência que somente é afastado com condenação judicial definitiva, nos moldes da mais recente interpretação do E. Supremo Tribunal (HC 187.180/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de julgamento: 19/06/2020). Com efeito, em consulta aos autos n. 1501051-73.2021.8.26.0571, verifica-se que se trata de feito ainda em tramitação, para apreciação do recurso de apelação defensivo. É justamente por essas razões, amparadas em precedentes da E. Suprema Corte, que se requer a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. De tal forma, ante as peculiaridades do caso em tela, claro está que não há razão para a determinação de regime fechado, ainda que não se aplique o redutor em seu grau máximo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LEONARDO CÉSAR ROSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea "J", do Código Penal, porque, no dia 12 de março de 2021, em período de anormalidade - Pandemia, na Rua Agides Ravaci, próximo ao n. 85, Jardim Nova Era, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dez porções de "maconha", com peso de 12,92 gramas. O Réu foi

notificado, fls. 121, e apresentou defesa preliminar, fls. 125/126. A denúncia foi recebida, fls. 127/128, e o Réu, citado, fls. 145. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação e a aplicação de benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 07/08, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 09/10, bem como no Laudo de Constatação, fls. 12/15 e de Exame químico-toxicológico n. 82611/2021, fls. 73/75, constatando-se a presença do princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (MACONHA). Sandro Luiz Costa Silva e Cláudio Felipe Fernandes, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando foram parados por uma pessoa, que noticiou o tráfico de entorpecentes por alguém, cujas características foram passadas. Foram ao local e se depararam com o Réu com o qual as porções de "maconha" foram encontradas. Ele disse que as drogas eram para seu uso. Leonardo César Rosa da Silva, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram suas, mas para uso pessoal. Tinha acabado de adquiri-las. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois, com o Acusado, houve apreensão de porções de entorpecentes em pequena quantidade, compatíveis com a destinação própria, havia poucas unidades e não foi presenciado qualquer ato de fornecimento. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque foram apreendidas consigo, todavia, ausentes informações de venda, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, LEONARDO CÉSAR ROSA DA SILVA, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 10 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA